



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0045841-72.2017.8.26.0050 - Controle nº 1064/2017**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JOSE PERGENTINO DORNELAS LEITE JUNIOR**

Juíza de Direito: Dra. **Eliana Cassales Tosi**

Vistos.

JOSE PERGENTINO DORNELAS LEITE JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 31 de maio de 2017, por volta das 05h00min, na Rua Aureliano de Beruete, altura do nº 35, Grajaú, nesta capital, vendeu, expôs à venda, ofereceu, tinha em depósito e trazia consigo drogas, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Extrai-se da denúncia que, ao que se apurou na ocasião dos fatos, policiais militares foram até aquele local pois sabiam que lá havia comércio ilegal de drogas e quando chegaram, avistaram José em atitude suspeita, pois ali aguardava em um ponto fixo por consumidores, sendo que ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir. Por se tratar de atitude própria do tráfico de drogas, os milicianos abordaram o denunciado e com ele apreenderam uma sacola plástica contendo em seu interior 25 pequenos embrulhos recheados de maconha, 12 pedras de crack, 62 pinos plásticos que continham cocaína, previamente confeccionados e prontos para a comercialização. Conclui a inicial que José foi preso e autuado em flagrante e as substâncias apreendidas e periciadas onde constatou-se tratar de 41,7g de maconha, 3,1g de crack e 28,5g de cocaína, que são substâncias entorpecentes e que provocam dependência física e psíquica. O acusado foi notificado (fls.81), sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública que apresentou Defesa Preliminar a fls. 87. A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de agosto de 2017 (fls.88). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum pelas partes, Policial Militar Weverton Pereira da Silva e Policial Militar Marcio Fernando de Oliveira. Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates orais, conforme acima consignado. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente. A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. A peça acusatória está amparada na prova da materialidade – Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência nº 1949/2017 – fls. 7/10; Auto de Exibição e Apreensão – fls. 11; Laudo de Constatação nº 237694/2017 a fls. 13/15 e laudo de exame químico toxicológico – 76/78, cuja conclusão foi resultado **positivo para Cocaína e Tetrahydrocannabinol**, bem como a prova oral colhida. A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas. **Foi ouvida em juízo a testemunha Policial Militar Weverton Pereira da Silva**, extraindo-se de seu depoimento, em suma, que estavam em patrulhamento e no local diariamente cai ocorrência de tráfico de entorpecentes. No dia abordaram o réu com uma quantidade de drogas que foi encontrada por seu parceiro, policial Marcio Fernando e estavam no bolso do réu. Acha que era cocaína, maconha e crack. O réu também tinha dinheiro, mas não se recorda o valor. A droga estava em uma bolsinha, a cocaína em eppendorfs, a maconha em quadradinhos e o crack em saquinhos. O local é uma espécie de viela e o réu não chegou a ver a aproximação dos policiais. O réu esboçou reação de tentar correr, mas não conseguiu. Acha que tinha moradores no local da prisão. **Em juízo também foi colhido o depoimento da testemunha Policial Militar Marcio Fernando de Oliveira,**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

extraindo-se de seu depoimento, em síntese, que durante patrulhamento encontraram um indivíduo em um local de difícil acesso. O réu demonstrou certo nervosismo. Em abordagem localizou no bolso direito do réu um pacote com entorpecentes. Tinha droga em variedade, se não se engana, maconha, cocaína e crack. A droga estava embalada de forma individual para a venda. O réu assumiu que estava vendendo e já estava há uns dias naquele local. Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos Policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, acrescentando-se que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido TJSP: ***“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).*** Estão presentes importantes evidências que apontam a narcotraficância, tais como: **a)** pela considerável quantidade de porções de drogas apreendidas com o réu; **b)** pela forma de acondicionamento das drogas; **c)** pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros. Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. **Reconhecida a ocorrência do delito de tráfico e a responsabilidade do acusado, passo à fixação da pena:** Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico **na primeira fase** que o réu, com 19 anos à época dos fatos, é **primário** e não ostenta qualquer antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena-base, conforme se infere da folha de antecedentes a fls. 72. Assim, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na **segunda fase** reconheço a circunstância atenuante da **menoridade**, mas deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: ***“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”***. **Em terceira fase**, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. No caso em tela, o réu é **primário e menor**, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, por não ser desprezível a quantidade e diversidade de droga apreendida (25 invólucros contendo maconha; 62 microtubos com cocaína e 12 invólucros com crack – fls. 11), **diminuo a pena de metade**, culminando com 2 anos e 6 meses de reclusão e a pecuniária de 250 dias-multa. Registre-se que, consoante os ensinamentos de Ricardo Antonio Andreucci, em Legislação Penal Especial, Editora Saraiva, 3ª Edição, 2007, pág. 54: ***“Portanto, caberá ao Ministério Público, no processo, provar que o agente se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Sem essa prova, a causa de diminuição de pena não poderá deixar de ser aplicada, satisfeitos os demais requisitos legais”***. (grifos nossos). No mais, considerando a quantidade, diversidade (cocaína e maconha) e a natureza da droga apreendida, inviável maior redução da pena. Considerando as razões expostas durante a aplicação da pena, a **primariedade, menoridade** e, considerando, também, que a quantidade de droga apreendida ao menos denota que não se trata de estruturado tráfico de drogas, fixo o regime **semiaberto**, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal. O crime em comento não é equiparado a hediondo. No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é **primário, menor** e realizava tráfico de pequena monta para terceiro, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante. Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, *Habeas Corpus* nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora:

0045841-72.2017.8.26.0050 - lauda 2


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa: “(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, **é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de prisão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal.** (...)”. (grifos nossos). E, conforme já decidiu o Excelso Pretório: “Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. **Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha.** Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. **Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade.** Reprimenda inferior a quatro anos, **reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.** Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. **Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF**”. (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos). Consoante elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: “**TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 132,2 gramas de maconha e 57 gramas de cocaína. Configuração. Prisão em flagrante. Confissão policial. Retratação em juízo isolada. Depoimento dos policiais militares, que o prenderam em flagrante. Intuito mercantil evidenciado. Natureza, quantidade e modo de acondicionamento. Não comprovação, ademais, de atividade lícita remunerada. Ausência de condição financeira para suportar as despesas do consumo pessoal. Condenação mantida. PENA. Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedentes do STJ e do STF. Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Fixação do regime aberto. Correção dos dias-multa. Apelo defensivo parcialmente provido para estes fins**”. (TJ-SP - APL: 00872974120138260050 SP 0087297-41.2013.8.26.0050, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 14/04/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/04/2015). (grifos nossos). Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na **prestação de serviços à comunidade**, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de **multa**, no valor de dez dias-multa, que se somarão à pena pecuniária anteriormente imposta, tudo, com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, e artigo 46, do Código Penal. A substituição é permitida, desde que hajam requisitos legais, pelo HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e Resolução nº 5, de 2012, do Senado Federal. Registre-se, por oportuno, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça determinou a revisão do entendimento consolidado pela Terceira Seção no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600 (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/03, DJe 26/04/2013), a fim de acolher a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo. **PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada**

0045841-72.2017.8.26.0050 - lauda 3


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. **Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.** (STJ – Petição nº 11.796 – DF (2016/0288056-2), Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Data de Julgamento: 23/11/2016, Terceira Seção). (grifos nossos). **DISPOSITIVO** Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **JOSÉ PERGENTINO DORNELAS LEITE JÚNIOR**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, impondo a pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial **semiaberto**, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa, da forma anteriormente especificada, além da pecuniária no valor de 250 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo. A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida. Considerando que o Réu foi beneficiado com a liberdade provisória e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deve ser facultado ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea *a*, da Lei Estadual nº 11.608/03, condeno o réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária. Defiro a incineração da droga apreendida, com as cautelas da lei, nos termos do artigo 32 da Lei nº. 11.343/06, oficiando-se ao D. Delegado de Polícia para as providências cabíveis, reservando-se quantidade suficiente para contraprova (capítulo V, seção V, item III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). Com o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. **Publicada** esta em audiência, **registre-se e cumpra-se**, saindo as partes **intimadas**, inclusive quanto ao prazo recursal. **Tendo em vista que ambas as partes manifestaram que não pretendem recorrer da sentença, pela MM. Juíza foi dito: por ser revel, intime-se o réu da sentença por meio de edital. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado para as partes e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (para cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade), encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente. Elabore-se o cálculo da multa, intimando-se o réu para pagamento no prazo de dez dias. Certifique a zelosa Serventia a existência de objetos apreendidos sem destinação, vindo a seguirem conclusos, se for o caso. Autorizo xerox. NADA MAIS.**

São Paulo, 23 de novembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**